

1500042-05.2022.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... qual tem a propriedade/posse, para o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ocorre que, no dia 15 de janeiro de 2022, diante de inúmeras denúncias dando conta da prática do narcotráfico por KAUAN, policiais militares realizaram diligências no endereço acima mencionado, já conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, e avistaram KAUAN na via pública. Realizada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500042-05.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500042-05.2022.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013657/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 22465909 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 116/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2013657 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN VICTOR BRAZ e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

MARCOS PAULO RAMOS DONEGA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput e §1º, inciso III, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de crimes, bem como KAUAN VICTOR BRAZ, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de crimes.

Consta do incluso inquérito policial que, em data e horário indeterminados, porém antes do dia 15 de janeiro de 2022, nesta cidade e comarca de Limeira, MARCOS e KAUAN associaram-se entre si e com terceiro até o momento não identificado para a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta ainda que, no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 12h05min, na Avenida Vitorio Bortolan, Parque Residencial Abílio Pedro, nesta cidade e comarca de Limeira, KAUAN, em atividade de tráfico ilícito, trazia consigo, para serem

entregues ao consumo de terceiros, 11 (onze) porções de cocaína, pesando cerca de 03g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que, no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 12h05min, Rua Eusébio Villar, 562, Parque Nossa Senhora das Dores IV, nesta cidade e comarca de Limeira, MARCOS, em atividade de tráfico ilícito, guardava e tinha em depósito, para serem entregues ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de maconha, pesando cerca de 03g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como também, nas mesmas circunstâncias utilizava e consentia para que outrem se utilizasse do imóvel situado no local acima mencionado, do qual tem a propriedade/posse, ainda que este documento gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Segundo apurado, na primeira ocasião acima relatada, em data incerta, porém anterior ao dia 15 de janeiro de 2022, os acusados associaram-se entre si e com terceiro até o momento não identificado e passaram a explorar o tráfico ilícito de drogas, de forma organizada, sendo que KAUAN realizava a venda dos entorpecentes e, em seguida, entregava a quantia obtida com o narcotráfico para MARCOS, que guardava as quantias em sua residência e, em seguida, entregava ao terceiro não identificado, o qual passava no local para recolher o dinheiro obtido.

Apurou-se, também, que, já configurando a segunda ocasião acima descrita, KAUAN trazia consigo drogas para fins de comercialização. Por fim, configurando a terceira ocasião acima narrada, apurou-se que o MARCOS guardava e tinha em depósito drogas para fins de comercialização, bem como utilizava e consentia que outrem se utilizasse do imóvel situado no endereço alhures mencionado, do qual tem a propriedade/posse, para o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ocorre que, no dia 15 de janeiro de 2022, diante de inúmeras denúncias dando conta da prática do narcotráfico por KAUAN, policiais militares realizaram diligências no endereço acima mencionado, já conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, e avistaram KAUAN na via pública. Realizada a abordagem, com ele foram encontradas 11 (onze) porções de cocaína, drogas que trazia consigo para serem entregues ao consumo de terceiros.

Indagado na ocasião, KAUAN confessou a prática do narcotráfico e informou que o dinheiro arrecadado com as vendas deste entorpecente foi entregue a MARCOS, apontando o endereço deste.

Ato contínuo, os agentes públicos dirigiram-se ao endereço fornecido, o qual também já havia sido objeto de denúncias anteriores e fica próximo ao local da abordagem, e encontraram MARCOS sentado defronte do imóvel.

Ao ser questionado, MARCOS confirmou que era responsável por ficar com o dinheiro das drogas que eram vendidas, apontando KAUAN como um dos traficantes que deixava o dinheiro oriundo da traficância em sua residência. Ato contínuo, o aludido denunciado apontou o local utilizado para ocultar os valores.

No local mencionado, a saber, em uma coberta que estava em uma mesa na garagem, os agentes públicos localizaram 01 (uma) porção de maconha, droga que MARCOS ali guardava e tinha em depósito para serem entregues ao consumo de terceiros, além da quantia de R\$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), a qual era por ele guardada em sua residência para, posteriormente, ser entregue ao terceiro não identificado.

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação dos réus para que apresentassem defesas preliminares, que vieram aos autos (fls. 138/144 e 158/159).

A denúncia foi recebida em 14 de março de 2022 (fls. 163/164).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, com interrogatório dos réus ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Memoriais escritos da acusação (fls. 256/264) e da defesa de Kauan (fls. 269/288) e de Marcos (fls. 291/294).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudos definitivos com resultado positivo para “cocaína” (fls. 21/24 e 113/115), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa, com ressalvas.

Perante a autoridade policial, o réu MARCOS disse que policiais militares foram até sua casa, onde ele estava sentado e indagaram o que tinha lá. Os policiais ingressaram na residência e encontraram dinheiro, cuja quantia não sabe. Esclarece que os meninos que traficam deixam o dinheiro em sua casa, onde guarda e depois entrega este dinheiro para um indivíduo que chega em um veículo Corola ou Civic de cor preta, cujo nome do indivíduo não sabe. Disse que KAUAN é um desses indivíduos que deixa o dinheiro em sua residência. Alega que a porção de maconha encontrada em sua casa é sua e é destinada ao seu consumo pessoal, uma vez que faz uso de maconha. Nega envolvimento com o tráfico de drogas (fls. 15).

Em Juízo, o réu MARCOS disse que tem 45 anos. Trabalha como pintor. Sua mãe foi constrangida. Está pagando pelo seu passado. Já cumpriu pena. Começou a trabalhar como pintor. Frequentava a casa da sua genitora. Todo dia frequentava aquele local. Conhece KAUAN pois prestou serviços ao pai dele. Frequenta a casa da sua sogra. O dinheiro era fruto do seu trabalho. Foram localizados mil duzentos e cinquenta reais. Falou que iria comprar um compressor de ar. Precisava comprar um para trabalhar. Pegou oitocentos reais de Tatiane. Depois pegou mais quatrocentos reais com Murilo. Colocou o dinheiro debaixo da coberta. Costumava fumar um baseado. A maconha encontrada é de sua propriedade. Foi abordada pela policial Karine por três vezes. Também já foi abordado pelo policial Leandro. Nega a prática do tráfico e da associação. No dia da prisão, KAUAN pediu uma garrafa de água. Parou três motos da polícia, falou que não iria sair da casa. Estava assinando carteirinha. Foi puxado para fora. Eles queriam as drogas. Falaram que a casa dele caiu. Apontou onde estava a maconha, era para seu consumo pessoal. Não deu autorização para que eles entrassem. O dinheiro foi localizado numa coberta. Disse na hora do que se tratava, era para comprar um compressor. Falaram que KAUAN estava preso. Prestou serviço a Tatiane e a mãe dela. Ganhou isso como forma de pagamento, dois dias antes da prisão. Já estava sofrendo ameaças. Os policiais forjam prisões quando encontram dinheiro. O compressor que queria comprar custa em torno de mil e setecentos reais. Prestou serviços para um monte de pessoas. Não pode andar com esse dinheiro em seu poder, tem passado criminoso. Não se recorda se falava com KAUAN. O celular apreendido era seu, dificilmente falava com ele. O telefone é de uso comum dele e dos filhos (mídia).

Perante a autoridade policial o acusado KAUAN disse que estava pela rua usando drogas e acabou ficando pela rua. O "gerente" da biqueira, que não conhece, passou no local e deixou drogas para que as vendesse. Informa que era o último pacote que iria vender, sendo que deixou o dinheiro com MARCOS, uma vez que ele é seu conhecido. Informa que pegaria o dinheiro após ir embora, sendo que não costuma deixar dinheiro na casa de MARCOS (fls. 17).

Em Juízo, o acusado KAUAN disse que tem 18 anos. Trabalha numa lanchonete. Não acharam nada de ilícito com ele. Queriam que ele colocasse a culpa em MARCOS. Não sabia nada a respeito dele. Negou tudo aos policiais e na delegacia. As drogas foram localizadas numa árvore, não era de sua propriedade. Só foi comprar um baseado naquele bairro. Não queria ficar parado na biqueira. Passou na casa de MARCOS naquele dia. Foi pedir água na casa dele. Depois foi na biqueira. Foi detido. Não conhecia os guardas, foi encurralado. Não é verdade que vendia drogas na rua. Os guardas já sabiam onde era a casa de MARCOS. Trabalha de domingo a domingo, no período da tarde. Foi na balada. Ficou na casa da menina das oito da manhã até às dez e meia. Depois foi comprar droga. Não queria ficar parado, ficou zanzando para não ser enquadrado. Ficou quinze minutos no local da prisão. Não havia pedido a droga. Quando foi buscar o baseado passou na casa de MARCOS. A menina não foi com ele na biqueira. Na árvore foram encontrados pinos de cocaína. Faz uso de cocaína, mas naquele dia não usou. Não leu papel antes de assinar na delegacia. Tinha mais contato com o filho de MARCOS por celular. Conversava com MARCOS, era contato do dia a dia (mídia).

A versão extrajudicial dos acusados convence e encontra amparo na prova oral colhida, o que corrobora a condenação de MARCOS no delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e de KAUAN no artigo 33 da Lei de Tóxicos, como adiante se verá.

A policial militar Karine Pereira da Mota disse que os acusados foram presos pela prática de tráfico de drogas. Estava de serviço e existiam várias denúncias pela Avenida Vitório Bortolan. O local é muito conhecido pela traficância. As denúncias apontavam as características de KAUAN. Em poder dele localizaram onze porções de cocaína. Indagado, ele disse que estava desde a manhã vendendo drogas. Todo o dinheiro era entregue em favor de MARCOS e apontou o endereço localizado na Rua Euzébio Vilar, nº 562. Aquela casa também já havia sido objeto de denúncias anteriormente, ficando próxima de onde KAUAN foi abordado, cerca de três a quatro ruas. Na casa, MARCOS estava sentado em frente e, indagado, ele confirmou que era responsável por ficar com o dinheiro das drogas vendidas. MARCOS apontou KAUAN como um dos traficantes que deixava dinheiro em sua residência. MARCOS apontou que em uma coberta que estava em uma mesa na garagem estava o dinheiro, sendo que no referido local encontraram uma porção de maconha e a quantia de R\$.1250,00 (mil duzentos e cinquenta reais). Diante dos fatos, deram voz de prisão. Já havia denúncias de tráfico em dias anteriores. Foram saber da real situação no dia da prisão, quando eles foram indagados. A traficância naquele bairro é muito forte. A quantia em dinheiro localizada seria do período da manhã, várias pessoas vendiam drogas. Apreenderam telefones celulares que eram dos autuados. A mãe de MARCOS disse que a residência era dela, ela não tinha ciência do dinheiro, ele guardava sem o consentimento dela. Já havia abordado MARCOS anteriormente, a prática de tráfico é diuturna. A entrada foi franqueada pelo réu. A mãe de MARCOS saiu posteriormente, fizeram busca apenas na garagem, a mãe franqueou a entrada. Não ingressaram na casa. A genitora não tinha conhecimento do que seu filho fazia (mídia).

O policial militar Leandro Rafael de Almeida contou que receberam denúncias de que KAUN praticava o tráfico de drogas pela Avenida Vitorio Bortolan. Viram que KAUAN estaria traficando no local e, efetuada a revista pessoal, foram encontradas 11 porções de cocaína. Indagado, KAUAN confessou que estava traficando desde o período da manhã e que já havia vendido algumas porções de cocaína. Ao ser indagado o motivo de não estar com o dinheiro dessas drogas vendidas, KAUAN disse que tinha

deixado o dinheiro na residência de MARCOS e indicou o endereço. Diante dessa informação, foram até a residência localizada na Rua Euzébio Vilar, nº 562, conforme indicada por KAUAN. A casa ficava próxima de onde KAUAN foi abordado. Na casa, MARCOS estava sentado em frente à casa e, indagado, ele confirmou que era responsável por ficar com o dinheiro das drogas que eram vendidas. MARCOS apontou que em uma coberta que estava em uma mesa na garagem estava o dinheiro, sendo que no referido local encontraram 1 porção de maconha e a quantia de R\$.1250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais). A denúncia dizia respeito ao KAUAN. Ambos disseram que só se conheciam de vista. Foram apreendidos telefones celulares. Já conhecia MARCOS de outras abordagens. A mãe de MARCOS também franqueou a entrada. Não chegaram a entrar na casa, só ficaram na garagem, o filho dormia naquele local. A mãe disse que ele dormia alguns dias lá (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente os réus.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, “a priori”, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais “lato sensu”. Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Foram ouvidas testemunhas de defesa.

A testemunha Cleuza Divina Crepaldi disse que é sogra de MARCOS. Foi ouvida como informante. Mora no local da prisão de KAUAN. Sabe que MARCOS frequentava a sua casa para cuidar dela e depois iria trabalhar. Como é acamada, seu genro sempre a ajudou. Ele era pintor (mídia).

A testemunha Idenis Ramos de Oliveira contou que é mãe de MARCOS. Foi ouvida como informante. Estava na residência com seu neto. Ouviu um barulho. Viu dois policiais puxando seu filho para fora. Juntaram mais policiais. Ele foi levado para fora. Depois foi levado para dentro da casa. Começaram a fazer um monte de perguntas a ele, com um revólver apontado na cabeça. Ele deveria confessar. Começou a passar mal. Os policiais foram na sala e no banheiro, permitiu a entrada deles. Tinha certeza que não tinha nada de errado no seu imóvel. MARCOS não mora nesse local. Seu esposo está acamado. MARCOS a ajudava com afazeres domésticos. Ficou sabendo do

encontro de dinheiro. Depois tomou conhecimento que o dinheiro seria para a compra de um compressor. Não contou isso aos guardas. MARCOS trabalhava como pintor. No dia da prisão ele só foi ajuda-la, depois ele iria trabalhar. Ele estava sentando na área da varanda quando ocorreu a prisão. Seu filho sempre ia até a sua casa, só ele podia ajuda-la. Ele costumava ficar na frente do seu imóvel, nunca viu nada de estranho nisso. Quando deu notícia a sua nora ela disse que o dinheiro seria da compra do compressor, era um valor de oitocentos reais (mídia).

A testemunha Tatiane Lorizolla dos Santos disse que tem amizade com a mulher de MARCOS. Também conhece KAUAN. Foi ouvida como informante. Conhece MARCOS desde que moraram juntos. Ele é um bom pintor. MARCOS fez vários serviços a ela e familiares. Nunca ficou sabendo que ele era traficante. Estranhou a prisão. Descreveu a rotina de trabalho do acusado MARCOS. Sabe que MARCOS morava com a esposa (mídia).

A testemunha Murilo Alexandre Braz disse que é pai do KAUAN. Foi ouvido como informante. Tem relação de amizade com MARCOS, ele prestou serviços de pintura. Tem um trailer. MARCOS pintou a sua casa. Seu trailer foi pintado pelo réu MARCOS. KAUAN deu muito trabalho na adolescência e ficou assustado com o que aconteceu. Seu filho trabalhava numa lanchonete no período da tarde. Nunca proibiu seu filho de se divertir na balada. Não sabe onde seu filho ficava de manhã. Sabe que MARCOS mora com a esposa e filhos (mídia).

Passo a analisar os crimes separadamente.

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas)

Pelo teor da prova oral colhida, policiais militares realizaram diligências em conhecido ponto de tráfico ilícito de entorpecentes e avistaram KAUAN na via pública. Na abordagem, com ele foram encontradas onze porções de cocaína.

Indagado, KAUAN admitiu aos agentes a prática do narcotráfico.

No local indicado por KAUAN, os policiais encontraram MARCOS sentado defronte ao imóvel.

Os policiais militares não viram em qualquer momento KAUAN entregando dinheiro a MARCOS. A quantia em dinheiro localizada (R\$1250,00) estava na mesa de passar roupa da residência da genitora dele, havendo confirmação pelas testemunhas de defesa Tatiane e Murilo que o réu MARCOS havia lhes prestado serviço de pintura, pagando pela prestação.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado tão somente quanto ao corréu KAUAN, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína).

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão

Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal;
Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga à terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos envolvendo o acusado KAUAN.

A situação do acusado MARCOS, por sua vez, é diversa.

No tocante à finalidade com que ele tinha substância entorpecente, não ficou comprovado cabalmente ser a sua intenção entregar a substância ao consumo de terceiros. Com efeito, a quantidade de droga apreendida (uma porção de maconha) não era incompatível com o uso e o acusado disse em todas as oportunidades em que interrogado que é usuário de drogas e aquele entorpecente seria para seu próprio uso.

Por outro lado, os policiais militares não presenciaram qualquer ato de tráfico. Contra o réu pesa apenas o fato de ele ter sido surpreendido em poder de maconha e a sua conduta suspeita.

Diante de um arcabouço jurídico igual ao que se apresenta, preocupado com a proteção da inocência presumível de todos (cf. artigo 5º, inciso LVII, da CF), que impõe ao Juiz a livre apreciação da prova, não podendo dar exclusivo valor nos elementos informativos colhidos durante a investigação policial (cf. artigo 155 do CPP), sem vínculo a laudo pericial (cf. artigo 182 do CPP) ou mesmo à confissão do acusado (cf. artigo 197 do CPP), parece ser indispensável que o juízo penal condenatório seja vazado com prova indubitável e cristalina, inequívoca e concludente mesmo, sem deixar margem a dúvidas.

No caso desta ação penal que se discute, parece visível que a prova colhida é insuficiente para compor um justo e adequado juízo de reprovação penal da conduta imputada ao acusado MARCOS.

Aliás, ainda quanto a isso, os policiais não foram capazes de sustentar que surpreenderam o acusado praticando tráfico de drogas.

Havendo dúvidas acerca da existência de tráfico, deve-se decidir em favor do réu MARCOS:

"TRÁFICO DE DROGAS - Não comprovação de atos de traficância - Circunstâncias da prisão que não indicam, por si, e de forma segura, atos de mercancia - Réu que sustenta ser usuário da droga - Recurso provido para desclassificar para uso próprio (voto nº 39073)". (TJSP; Apelação Criminal 0006634-19.2015.8.26.0153; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019).

"APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recursos ministerial e defensivo. Réu surpreendido na posse da droga apreendida. Palavras dos policiais militares que merecem credibilidade. Absolvição inviável. Possibilidade de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 em vista da ausência de comprovação da destinação ao tráfico. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Acusado primário e menor relativo. Pena de advertência que se mostra adequada e suficiente. Prejudicada a análise do pleito do Ministério Público de reconhecimento do crime de associação para o tráfico. Recurso defensivo parcialmente provido e recurso ministerial improvido." (TJSP; Apelação Criminal 0000471-84.2018.8.26.0616; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 09/10/2019).

"Apelação. Tráfico de entorpecentes. Provimento para desclassificar o delito pelo qual foi condenado para o do artigo 28 da Lei de Drogas, aplicando-se a pena de advertência sobre os efeitos da droga". (TJSP; Apelação Criminal 0001189-48.2018.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019).

E afasto a inconstitucionalidade do tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas e tal não se justifica mediante o reconhecimento de que a tipicidade dessa conduta se vincula às propriedades da droga e ao risco social e à saúde pública, e não à lesividade em concreto.

Ou seja, em se tratando de crime de perigo presumido ou abstrato, em que a pequena quantidade de substância entorpecente é própria do tipo, a conduta do réu viola a norma que visa a evitar exatamente o uso.

Considera-se ainda que o direito constitucional à privacidade do indivíduo não se sobrepõe ao interesse coletivo de proteger a saúde pública.

No mais, a decisão do Supremo Tribunal Federal ainda não é definitiva e o assunto está pendente de discussão naquela corte.

Conforme já restou decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“APELAÇÃO. USO PESSOAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONSTITUCIONALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. CONFISSÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida quanto ao crime de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente. Inteligência da Doutrina de Vicente Greco Filho e Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. Precedentes do TJSP (Ap. 0026791-41.2009.8.26.0050 9ª C Rel. Des. Sérgio Coelho j. 11.09.2014 DO 18.09.2014; 0031627-94.2010.8.26.0576 9ª C Rel. Des. Penteado Navarro j. 21.11.2013 DO 22.11.2013 e Ap. 0030836-79.2009.8.26.0344 1ª C Rel. Des. Marco Nahum j. 21.02.2011 DO 22.02.2011). (...) Improvimento ao recurso defensivo”. (TJSP; Apelação 0024759-53.2014.8.26.0320; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

Assim sendo, todas essas circunstâncias somadas determinam a desclassificação no tocante ao corréu MARCOS, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal, razão pela qual desclassifico a conduta descrita na denúncia para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico)

Por outro lado, em que pese a condenação pelo crime de tráfico de entorpecente envolvendo o acusado KAUAN, não há prova segura de que os réus agiam em associação.

Para o delito em questão, é exigida a estabilidade na união, já que a associação, com a finalidade que possui, baseia-se num plano criminoso que só se verifica com a permanência estável para consecução de seus objetivos.

Ressalto que as testemunhas ouvidas (policiais militares) nada mencionaram sobre eventuais notícias anteriores de que os réus praticavam o comércio de drogas conjuntamente. Tampouco se apurou há quanto tempo estavam ali traficando, já que a

prisão foi em flagrante delito, não havendo investigação aprofundada e pretérita consistente em interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, mandado de busca ou campanas.

Alías, o laudo pericial nos aparelhos de telefonia móvel (fls. 212/225 e 226/240) não trouxeram informações que pudessem contribuir com a apuração do delito em tela.

Não há evidências a configurar permanência e estabilidade, restando prejudicada a tipificação do delito. No caso em apreço, a associação existente entre os réus KAUAN e MARCOS, com todas as características acima apontadas, não foi suficientemente demonstrada.

Não há nos autos qualquer prova de que havia entre eles uma associação permanente e estável para o comércio de drogas.

Os indícios apontados pelo Ministério Público na inicial acusatória não são suficientes para a condenação do delito do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, eis que não há caracterização de organização criminosa estável e permanente entre os acusados. O delito de associação não se confunde com o mero concurso de agentes e não há prova segura que os réus estavam associados para a prática do tráfico de drogas, não se podendo construir o entendimento de que, pelas circunstâncias da prisão em flagrante e do local, haveria também o delito de associação ao tráfico.

Explica Guilherme de Souza Nucci em relação ao crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06:

"Associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes (...) Sob outro aspecto, a associação criminosa há de ser estável e permanente. Do contrário, seria somente um concurso de pessoas" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, v. 1. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017).

A conduta do artigo 35 da Lei de Drogas vem representada pelo verbo "associar-se", que significa agregar-se, unir-se. O dispositivo requer que duas ou mais pessoas se associem para o fim de, reiteradamente ou não, praticar os delitos dos artigos 33, caput e § 1º, e 34. Exige-se um mínimo de estabilidade e não um mero concurso de agentes.

A respeito do tema, cito os seguintes julgados:

"Apelação Criminal. Associação para o tráfico. Absolvição mantida. Ausência de prova suficiente do vínculo associativo estável.(...)". (TJSP; Apelação 0002567-30.2015.8.26.0470; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 28/11/2016; Data de Registro: 02/02/2017).

"Associação para o tráfico - Prova pouco esclarecedora sobre a presença de vínculo estável e duradouro - Mero concurso de agentes - Crime não caracterizado - Absolvição mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000094-32.2015.8.26.0580; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 02/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018).

"(...) APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Falta de prova inequívoca de que o acusado estivesse associado ao adolescente, de maneira estável, duradoura e organizada, para a prática dessa atividade criminosa, conforme se exige - Dúvida que deve favorecer a defesa - Absolvição pelo crime de associação decretada (...)".

(TJSP; Apelação 0021362-62.2011.8.26.0361; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 02/03/2018).

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Como é cediço, esta Corte Superior entende que, para a configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes. 2. Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe (HC 434.972/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018). 3. Na hipótese, a Corte local manteve a condenação do agravado pelo delito de associação ao tráfico de entorpecentes a partir dos elementos de sua prisão em flagrante, em contexto de tráfico de drogas, construindo o raciocínio de que, pelas circunstâncias da prisão e local, haveria também associação ao narcotráfico local. 4. Não tendo o Ministério Público Federal trazido argumentos hábeis o suficiente para a modificação do julgado, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no HC 684.427/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ a orientação jurisprudencial de que para configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é imprescindível a estabilidade e a permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes. Precedentes. 2. Relativamente a dosimetria do crime de tráfico, verifica-se que a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada, na hipótese, considerando a condenação da paciente pelo crime de associação. Acolhido o pleito absolutório e considerando a carência de outros elementos concretos que indiquem a dedicação da paciente ao tráfico de entorpecentes, é cabível o reconhecimento da aludida minorante. 3. Não tendo o Ministério Público Federal trazidos argumentos hábeis o suficiente para a modificação do julgado, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 495.575/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019).

"HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias, em nenhum momento, fizeram referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre o paciente e os integrantes da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho; na verdade, as instâncias de origem presumiram, com base apenas no local em que o réu foi preso em flagrante, que ele seria integrante do Comando Vermelho e, assim, proclamaram a condenação com base em meras conjecturas acerca de uma societas sceleris. 3. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados

em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva o ânimo a mover a conduta decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. 4. Uma vez que o corréu se encontra em situação fático-processual idêntica à do paciente, devem ser-lhe estendidos os efeitos deste acórdão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 5. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0148254-77.2018.8.19.0001. Extensão, de ofício, ao corréu."(STJ, HC 557.151/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020).

Em homenagem à regra do in dubio pro reo, é devida, pois, a absolvição dos acusados KAUAN e MARCOS no que tange ao crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, na falta de provas seguras da empreitada criminosa.

Art. 33, § 1º, inciso III, da Lei de Drogas (uso de local para o tráfico de drogas)

Entendo, por outro lado, que a imputação referente ao artigo 33, §1º, inciso III, da Lei 11.343/06 em relação ao réu MARCOS não subsiste, uma vez que houve desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas quanto ao delito principal de tráfico.

Ainda que assim não fosse, se o agente, no mesmo contexto fático, pratica tráfico de drogas propriamente dito simultaneamente à realização da conduta do artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei de Drogas, a ele deverá ser imputado tão somente o crime principal (art. 33, caput), restando absorvida a figura equiparada. A interpretação sistemática da Lei de Drogas somente autoriza a conclusão no sentido da aplicabilidade do tráfico equiparado quando a utilização de bem móvel ou imóvel para fins de tráfico for realizada por pessoas que não estão diretamente envolvidas no delito previsto no art. 33, caput (cf. MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Os crimes descritos na denúncia ocorreram num mesmo contexto fático, portanto, o delito tipificado nos artigos 33, §1º, III, deve ser absorvido pelo crime de tráfico previsto no artigo 33, caput, da mesma lei.

Deste modo, aplicável o princípio da consunção para absolver o réu MARCOS desta imputação, mas como não houve condenação no crime do artigo 33 da Lei de Drogas, fica prejudicado o delito em questão.

Demonstrada a parcial procedência da imputação contra os acusados, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

MARCOS PAULO RAMOS DONEGA

Nos termos do art. 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do fato, o tempo de prisão processual (15 de janeiro de 2022 até o presente momento), além da pouca quantidade de droga apreendida e confissão judicial/extrajudicial, aplico-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

KAUAN VICTOR BRAZ

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são inteiramente favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão

e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A natureza e quantidade de drogas apreendidas no caso em tela não justificam a exasperação da pena-base pois não se trata de quantidade elevada.

Não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante (confissão extrajudicial e menoridade), pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula 231 do Colendo STJ.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Na terceira fase, sendo o réu primário, de bons antecedentes, não havendo prova de que integra organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4^a, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-se definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Para que fique bem claro, na derradeira etapa do sistema trifásico, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada.

A esse respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário:

“Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda” (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2008).

O valor do dia multa será no mínimo legal.

Considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido no HC 118.553/MS, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para admitir a fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

De fato, o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES.

Dessa forma, fixo o regime inicial aberto para o caso em questão.

Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do Colendo STF, que assim dispõem:

Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base

apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

No mais, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, aplica-se a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na fixação do regime prisional, assim como as decisões dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

Ante a quantidade da pena imposta, primariedade, confissão extrajudicial, menoridade e tendo em vista a decisão do STF no sentido de que o tráfico privilegiado não pode ser considerado como crime hediondo, além da natureza e quantidade de entorpecente localizada, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser definida em sede de execução criminal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para DESCLASSIFICAR a conduta envolvendo o acusado MARCOS PAULO RAMOS DONEGA, qualificado nos autos, para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de advertência.

Condeno o acusado KAUAN VICTOR BRAZ, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c a redução prevista no §4º do art. 33, ambos da mesma lei.

Por outro lado, ABSOLVO o réu MARCOS da imputação prevista no artigo 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP.

ABSOLVO ambos os réus da imputação prevista no artigo 35 da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Substituo a pena privativa de liberdade de KAUAN por duas restritivas de direitos, nos termos acima fundamentados.

Em razão da pena ora imposta, o réu MARCOS poderá recorrer em liberdade. Expeça-se o necessário.

O réu KAUAN poderá apelar em liberdade, condição a qual respondeu ao processo.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Proceda-se a devolução do dinheiro apreendido em favor de MARCOS, assim como do seu telefone celular, eis que houve desclassificação delitiva.

Decreto o perdimento do aparelho celular envolvendo o acusado KAUAN, porquanto fruto da traficância ilícita.

Após o trânsito em julgado, o nome dos réus deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA